

1502802-69.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... mm, bem como anotações referentes ao tráfico de drogas. Declarou que o acusado nada esclareceu sobre o material com ele apreendido. Consignou que o local dos fatos é conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas. Afirmou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos, mas soube por outros policiais que eles já o conheciam pela prática do tráfico de drogas, mas não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502802-69.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502802-69.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SOARES DE ALMEIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

RAFAEL SOARES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para fins de tráfico, 257 porções de maconha, 153 porções de crack e 129 porções de cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, em ocasião de calamidade pública, o réu portava três munições de calibre 9mm, picotados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi, também,

apreendido, na sacola plástica que o acusado portava, um caderno com anotações. Recebida a denúncia, o réu foi citado e ofereceu resposta à acusação. Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, realizaram-se os debates.

O Ministério Público pediu a procedência da ação, para condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos quanto ao apenamento, pleiteando a fixação da pena-base acima do mínimo legal quanto ao crime de tráfico de drogas e a fixação da pena-base em seu mínimo legal quanto ao delito de porte de munições, com o reconhecimento das circunstâncias agravantes relativas à calamidade pública e à reincidência quanto a ambos os crimes e a não aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, pediu a fixação do regime prisional fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por falta de provas quanto a ambos os crimes. Especificamente quanto ao crime de porte ilegal de munições, requereu a absolvição do acusado diante da atipicidade de conduta por ausência de demonstração técnica sobre a eficácia dos projéteis e por aplicação do princípio da insignificância, pugnando, ainda, que esta conduta do acusado fosse reconhecida como causa de aumento de pena do crime de tráfico de drogas, e não como crime autônomo. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base em seu mínimo legal quanto aos dois delitos, com o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico-toxicológico, pelo laudo pericial relativo às munições, pela prova oral colhida, bem como pelo restante do conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria deste delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática dos crimes descritos na denúncia. Disse que havia acabado de entrar em um beco próximo à sua casa, onde conversou com o dono de um salão com quem cortaria o cabelo, porém este lhe disse que iria tomar café e retornaria. Contou que ali permaneceu aguardando, porém aquele demorou e, em dado momento, cerca de cinco ou seis viaturas aproximaram-se. Disse que a primeira equipe policial foi ao fundo do beco, onde permaneceu por algum tempo, e então outras equipes policiais aproximaram-se e o abordaram. Contou ter dito aos policiais, de pronto, sobre sua condição de foragido e estes policiais o levaram até o local onde ocorre o tráfico de drogas. Alegou que os policiais que estavam no fundo do beco retornaram e trouxeram com eles uma sacola, cuja propriedade lhe foi atribuída indevidamente. Disse que não correu para o fundo do beco e não saiu da frente do salão. Contou que o indivíduo com quem cortaria o cabelo retornou ao local quando já estava abordado e algemado e não viu quando os policiais trouxeram a sacola do beco. Alegou que os policiais não lhe mostraram o conteúdo da sacola trazida do beco e lhe disseram haver somente droga nela. Declarou que trabalhava como ajudante de pedreiro com seu padraсто.

Entretanto, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se a realização do tráfico bem como o porte de munições por ele. Além disso, a versão por ele apresentada em Juízo não é crível em face do restante das provas produzidas durante o processo.

A testemunha policial militar Paulo de Jesus Ribeiro, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, durante patrulhamento em operação para coibir delitos no bairro Vila Margarida, avistou o réu, que estava com uma sacola branca nas mãos e viu que ele, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga. Narrou que foi ao encalço do acusado, conseguindo abordá-lo ao final de um beco, sob palafitas. Disse que, na sacola encontrada com o acusado, havia crack, cocaína e maconha, em quantidade que não recordou, além de munições de calibre 9 mm e anotações referentes ao tráfico de drogas. Disse que não foi apreendido dinheiro. Relatou que, acerca de todo o material encontrado com o acusado, ele nada declarou.

Declarou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos e esclareceu que foi constatado, naquela ocasião, que ele era procurado pela justiça. Consignou que o local dos fatos é conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas. Afirmou que, durante a fuga, não perdeu o réu de vista em nenhum momento e que a sacola contendo drogas e munições foi carregada pelo acusado durante todo o percurso, sem ser dispensada. Asseverou que o réu estava sozinho. Disse que não foi encontrada arma de fogo com o réu.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar Daniel da Silva Brito, ouvida em Juízo, narrou que, em operação no bairro Vila Margarida, viu o acusado, que portava uma sacola, e este empreendeu fuga das equipes policiais. Disse que a equipe que estava à frente era constituída pelo depoente e seu parceiro policial Ribeiro e ambos foram ao encalço do acusado, sem perdê-lo de vista, tendo ele fugido para o final do beco, escondendo-se sob as palafitas, onde foi abordado em posse da sacola. Relatou que, nesta sacola, foram encontradas, maconha, crack e cocaína, em quantidade que não recordou, além de três munições de calibre 9 mm, bem como anotações referentes ao tráfico de drogas. Declarou que o acusado nada esclareceu sobre o material com ele apreendido. Consignou que o local dos fatos é conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas. Afirmou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos, mas soube por outros policiais que eles já o conheciam pela prática do tráfico de drogas, mas não soube se já havia sido apreendida drogas com ele anteriormente. Asseverou que a abordagem ao réu se deu em razão de sua conduta em, estando com uma sacola na mão, empreender fuga ao avistar as equipes policiais. Relatou que não foi localizado armamento em posse do réu.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra dos policiais militares, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a diligência ao local dos fatos, a abordagem do réu e a apreensão dos entorpecentes e munições que ele trazia.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).
No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.
2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).
Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).
3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de

Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Desnecessidade de comprovação de nexo causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino - Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva - Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais militares não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos destas testemunhas colhidos durante a instrução criminal mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização dos entorpecentes e das munições na posse dele, estando em perfeita consonância com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Note-se que as testemunhas policiais bem relataram ter avistado o acusado, em posse de uma sacola e em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, e afirmaram que ele, ao notar a presença de equipes policiais, empreendeu fuga até o fundo de um beco, escondendo-se sob palafitas, local em que foi abordado ainda na posse da mesma sacola anteriormente vista.

Afirmaram que, dentro dessa sacola, foram encontrados entorpecentes variados, além de munições de calibre 9 mm e caderno com anotações, sobre os quais o acusado não apresentou qualquer esclarecimento.

Deve-se ressaltar, ainda, que, ao contrário do alegado pela Defesa, a abordagem do réu foi motivada por sua conduta em empreender fuga em posse de uma sacola e tentar esconder-se da equipe policial, como bem esclarecido pelas testemunhas.

Apesar de haver quem entenda diferente, a regra é que uma pessoa que efetivamente não esteja fazendo nada de ilegal não se assusta ao visualizar uma viatura policial, não foge de policiais, não tenta se esconder de policiais. Pelo contrário, quem não tem nada a temer sente-se seguro com a presença policial.

Afirmaram ambos os policiais militares que eles não conheciam o acusado anteriormente aos fatos, nada havendo nos autos que indique estivesse sendo o réu, de qualquer forma, visado por estes agentes policiais.

A testemunha policial Paulo consignou que, naquela ocasião da prisão em flagrante, constatou que o acusado era procurado pela Justiça. Já a testemunha policial Daniel esclareceu ter tomado conhecimento, por outros policiais, que o acusado já teria sido abordado anteriormente.

As acusações feitas pelo acusado e pela Defesa contra os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório. Argumentos genéricos que visam a desprestigiar a Polícia como um todo em nada influenciam na prova colhida no presente caso.

Ainda, as contradições indicadas pela Defesa entre as versões judiciais e extrajudiciais das testemunhas policiais não se encontram presentes.

Note-se que, em solo policial, as testemunhas ressaltaram ter visto um indivíduo - sendo este o réu - em atitude suspeita e portado uma sacola plástica e que ele, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se.

Em Juízo, confirmaram ter visto o acusado em posse da sacola e que foi ele o indivíduo que empreendeu fuga, mas acabou por ser abordado ainda com a sacola em sua mão.

Ouvidas em solo policial, disseram as testemunhas, ao final de seus depoimentos, que, durante a abordagem, um indivíduo não identificado aproximou-se do acusado para resgatá-lo, o que foi evitado pelos agentes de segurança.

Já em Juízo, as testemunhas pormenorizaram toda a ação policial, detalhando a conduta do acusado que puderam observar até a abordagem do acusado e localização da

sacola contendo drogas, munição e um caderno de anotação em sua posse, salientando-se que nenhuma das testemunhas foi questionada especificamente acerca de uma tentativa de resgate do acusado quando já abordado.

Outrossim, destaque-se que nem mesmo o acusado indicou que outras pessoas estivessem no local dos fatos antes ou após sua abordagem e, da mesma forma, não informou que qualquer pessoa tenha dele se aproximado para resgatá-lo da ação policial.

Ao contrário, somente disse o réu que o dono de um salão, com quem cortaria o cabelo, e cuja identificação sequer forneceu, teria visto a abordagem já em curso, no momento em que já estava algemado, nada mais tendo presenciado.

Todas estas circunstâncias indicam, portanto, que o acusado efetivamente trazia consigo a sacola contendo as drogas, as munições e o caderno de anotações, não havendo qualquer dúvida de ser ele o autor dos delitos.

Saliente-se que nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Dessa forma, a versão apresentada pelo acusado, além de não se mostrar crível, restou absolutamente isolada do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se ao depoimento dos policiais que realizaram sua prisão em flagrante e com ele localizaram as drogas, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos policiais – que sequer conheciam o réu anteriormente aos fatos – e as diligências realizadas no curso da ação penal, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é, de fato, traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da variedade e da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação policial, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva da quantidade, natureza e variedade de drogas encontradas, e das demais circunstâncias em que as drogas e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310).

Por fim, a ausência de perícia grafotécnica quanto às anotações encontradas na posse do acusado em nada abalam os demais elementos de convicção amealhados aos autos quanto à autoria do crime de ilegalmente trazer consigo a grande quantidade de entorpecentes variados.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu por este delito é medida que se impõe.

Da mesma forma, não há dúvidas de que o acusado estava portando ilegalmente as três munições de calibre 9 mm.

O crime de portar munição de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo, portanto, típica a conduta de quem é preso com os projéteis, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Somente se demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo, acessório ou munição, atípica seria a conduta de portar ou de possuir esses objetos, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

Ocorre que o laudo pericial de fls. 121/123 foi expresso em atestar a eficácia e potencialidade lesiva dos projéteis apreendidos. Outrossim, não há nos autos, nos termos da fundamentação já exposta, qualquer elemento que afaste a autoria do réu no delito de porte de munições de arma de fogo do qual está sendo acusado.

Ressalte-se, ainda, que nenhum documento que autorizasse o acusado a portar o referido acessório foi pelo réu apresentado.

Finalmente, não incide no presente caso a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

A causa de aumento de pena supracitada deve ser reconhecida quando o delito de tráfico de drogas tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.

O réu, no presente caso, não portava arma de fogo, mas, sim, munições, que estavam dentro da mesma sacola onde estavam as drogas, não sendo possível o reconhecimento de que as munições apreendidas se destinavam, naquele contexto, a viabilizar o comércio de drogas.

Assim, a conduta de portar as munições, no presente caso, revela-se como delito autônomo.

Finalmente, diante do presente caso concreto, não é possível reconhecer-se a atipicidade do crime pela aplicação do Princípio da Insignificância, pois a conduta de porta a munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, deve ser considerada em conjunto com o tráfico de drogas praticado pelo réu, conforme fundamentação acima, não ficando demonstrada a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade. 3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1856980 - SC (2020/0006029-0), RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK ,TERCEIRA SEÇÃO , julgado em 22/09/2021).

Dessa forma, a prova acusatória é robusta e suficiente para uma condenação também quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, como já consignado.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

1. Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se o aumento da pena em 1/6, ficando sua pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente, conforme certidão criminal de fls. 129/130, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/6, a qual

resta fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor já estabelecido. Verifico, ainda, que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. Destaque-se, ainda, que, o uso de máscaras de proteção facial em espaços de acesso público localizados no território estadual, como medida para conter a disseminação da COVID-19, conforme disposto no Decreto nº 65.897 de 30 de julho de 2021 do Estado de São Paulo, permaneceu vigente até o dia 08 de setembro de 2022, quando tais medidas foram liberadas por meio do Decreto nº 67.096. Saliente-se, ainda, que, embora sem revogação expressa do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública neste estado, deve-se considerar que as medidas de contenção contra o avanço do novo coronavírus permaneceram vigentes até 08 de setembro deste ano de 2022 quando, por parecer do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo, verificou-se possível esta flexibilização dos regramentos.

A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em 1/6, ficando ela fixada em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade de drogas apreendidas, bem como da reincidência do acusado.

Não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas

restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS , Quinta Turma, julgado em 16/03/2017 , PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Da mesma forma, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização dos maus antecedentes ou reincidência para o aumento da pena nas primeiras fases da dosimetria e, ainda, suas considerações para fins de afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, posto que tal conjuntura, na primeira e segunda em relação à terceira etapa de dosagem das penas, possui natureza jurídica diversa.

Neste sentido, já decidiu o Pretório Excelso, confira-se:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. II Não procede a alegação de que a inexistência de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé pública. Precedentes. III Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV Não caracteriza bis in idem a consideração da reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. VI Réu que apresenta maus antecedentes, condição que impede a aplicação da referida causa de diminuição. VII - Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, p. 367-376).

Ainda no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. "1. Constatando-se que a paciente ostenta maus antecedentes, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra. "2. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante da agente, somadas à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder - mais de 3 quilos de maconha -, ademais, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa..." (STJ HC 230.835/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012).

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

2. Quanto ao delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/06:

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que não há razão para impor aumento sobre a pena-base, a qual resta fixada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente, conforme certidão criminal de fls. 38/39, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor já estabelecido.

Ainda, o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública, circunstância esta que deve ser reconhecida, na forma como disposto anteriormente. Impõe-se, portanto,

o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em mais 1/6, a qual resta fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor já estabelecido.

Outrossim, os crimes foram praticados em concurso material, devendo as penas ser somadas, o que resulta na pena final de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, no valor já fixado.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, diante da somatória das penas, além de ser o réu reincidente, cuidando-se de crime de porte ilegal de munições e de tráfico ilícito de entorpecentes, este cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RAFAEL SOARES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (quanto ao carregador de pistola), ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social, destacando-se a variedade e natureza das drogas, além da grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado. Ainda, o acusado é reincidente pela prática de mesma espécie de delito. A reiteração de condutas criminosas, evidencia a dificuldade do acusado em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, verifico presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 11 de novembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA